

1505678-68.2021.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico em larga escala.

Com efeito, apesar da negativa do acusado, os guardas civis ouvidos na presente data confirmaram que visualizaram o acusado mexendo em um cano, local onde, posteriormente, os servidores ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1505678-68.2021.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505678-68.2021.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAPHAEL LUIZ PEREIRA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Raphael Luiz Pereira, menor de 21 anos de idade, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 21h00min, na Rua Argemiro Mareti, altura do nº 117, Jardim Santa Teresinha, neste Município e Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de estabelecimentos de ensino, de locais de trabalho coletivo e de recintos onde se realizam diversões de qualquer natureza, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 114 (cento e quatorze) microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 76g (setenta e seis gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 104), apresentou defesa prévia (fls. 66/70) e a denúncia foi recebida aos 29 de novembro de 2021 (fls. 71/72).

O acusado foi citado (fls. 106).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa requer a improcedência da ação penal, com consequente absolvição do réu. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 04); pelo auto de constatação provisória de substância tóxica (fls. 09), pelo laudo pericial do local (fls. 88/93); pelo laudo pericial toxicológico (fls. 85/87) e por toda a prova oral colhida em juízo.

O guarda municipal Thiago Luan Rabelo Pereira disse que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, ponto já conhecido pela venda de drogas, quando viram o acusado retirando algo de dentro de um cano. Quando a guarnição se aproximou, ele tentou se evadir do local e dispensou objeto na calçada. Durante a abordagem, foi verificado que havia 28 pinos contendo cocaína naquele "kit" arremessado no chão. Ao ser questionado, o acusado disse que havia mais droga no cano onde ele estava inicialmente mexendo, tendo a equipe encontrado mais 3 (três) "kits" de drogas, totalizando 114 pinos de cocaína. Já havia abordado o acusado, mas nada ilícito apreendido nas ocasiões anteriores. Não havia outras pessoas perto do acusado antes da abordagem.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo guarda municipal Pedro Pereira da Silva Neto, que confirmou que o acusado estava sozinho mexendo no cano e não conversava com ninguém antes da abordagem.

Em solo policial, o acusado Raphael Luiz Pereira disse que as drogas não lhe pertenciam, mas sim a traficantes que correram quando visualizaram a equipe da guarda municipal. Disse que estava no local trocando umas ideias com o pessoal, "só fazendo hora" (fls. 06).

Em juízo, o acusado nega a acusação. Disse que no local existe um beer e o interrogando estava na fila, assim como havia outras pessoas aguardando no estabelecimento. Disse que quando os guardas civis se aproximaram, algumas pessoas da fila deixaram o local. Então, os guardas civis iniciaram a abordagem, sendo que um deles se distanciou e, quando retornou, disse que o acusado deveria ser algemado. Tentou evitar a abordagem, mas acabou sendo contido e conduzido à Delegacia de Polícia. Foi agredido por um dos guardas civis, que lhe ameaçou "colocar mais droga" se dissesse algo ao médico durante o exame. Disse que era constantemente abordado pelos mesmos guardas civis.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido.

(Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

PROVA - Depoimento policial - Valor - Credibilidade e responsabilidade equivalentes à palavra dos civis, máxime quando corroboradas pelo conjunto probatório -

Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 497.707-3/9-00 - Santos - 5ª Câmara Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 13.332).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico, em razão da quantidade e forma como os entorpecentes apreendidos estavam embalados, características típicas do tráfico em larga escala.

Com efeito, apesar da negativa do acusado, os guardas civis ouvidos na presente data confirmaram que visualizaram o acusado mexendo em um cano, local onde, posteriormente, os servidores municipais apreenderam três kits contendo porções de cocaína, além de um quarto kit dispensado pelo acusado, ao perceber que seria abordado, totalizando 114 porções daquela droga.

Tal não bastasse, os guardas civis afirmaram que não havia outras pessoas no local, assim como disseram que o acusado não estava na fila de estabelecimento comercial, mas, sim, mexendo no cano quando a viatura se aproximou.

Importante frisar que não há que se duvidar do relato dos guardas municipais na medida em que os servidores afirmaram que já haviam abordado o acusado e nada

apreendido com ele anteriormente, de modo que não vislumbra nenhum indício para que, exatamente nesta ocasião, imputem falsamente o crime ao acusado.

Bem de ver que o tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06 é misto alternativo, de modo que, comprovado que o acusado guardava e mantinha em depósito quantidade expressiva de droga acondicionada de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito:

"O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Portanto, a prova produzida é segura e não demonstra nenhum abuso praticado pelos guardas civis, ao contrário do que alegado pelo acusado, na medida em que as provas oral e pericial não o demonstraram.

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, entendo que a quantidade de droga apreendida é expressiva e justifica o recrudesimento da pena nesta fase, pois mantinha em depósito e guardava mais de uma centena de porções de cocaína, quantidade que justifica a exasperação da pena, a teor do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Desse modo, fixo a pena privativa de liberdade em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em segunda fase, incide a atenuante da menoridade relativa, de modo que a pena imposta retorna ao mínimo legal.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 88/93) revela que nas imediações do local onde os fatos ocorreram existem estabelecimentos de ensino, praça pública e unidade de saúde, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aquele seja o local especialmente visado pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía

entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias multa.

Ainda em terceira fase, não incide a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da lei n. 11.343/06, porque o acusado ostenta anterior execução de medida socioeducativa (fls.137/150) e permaneceu custodiado na fundação CASA por em razão de fato análogo.

É isso o que também demonstra a certidão estadual de distribuições de ações perante a Infância e Juventude Infracional (fls. 26/27), que revela o enorme número de feitos instaurados em desfavor do agente, inclusive com execução de medidas socioeducativas.

Com efeito, trata-se de agente que se dedica a atividades criminosas, sendo o caso de se obstar por completo a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da lei n. 11.343/06, que não menciona que o envolvimento àquelas atividades se refira apenas ao período da maioridade penal, sendo mesmo possível considerar o tempo de inimizabilidade para avaliar se o réu faz jus às benesses daquele dispositivo. A esse respeito:

Ainda nessa etapa, no meu ponto de vista, realmente não é caso de se aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas ao apelante, já que compartilho do entendimento do Juiz sentenciante no sentido de que ficou demonstrado que ele se dedicava a atividades criminosas, em razão de ter admitido que vendia drogas há uma semana, além de já possuir um registro por ato infracional perpetrado quando adolescente, equiparado ao tráfico (TJSP, Autos n. 007605-85.2017, Relator Des. Nelson Fonseca Júnior, 10ª Câmara de Direito Criminal, julgado aos 23/8/2018).

“[a] existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da minorante do §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais” (STJ, AgRg no REsp nº 1.560.667- SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. em 17.10.2017, DJe 23.10.2017).

Como já dito, ostentando envolvimento em atividades criminosas, o agente não faz jus ao benefício destinado a iniciantes na seara delitiva, razão pela qual fica afastada a aplicação da minorante mencionada.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

Anoto que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao acusado e ensejaram a exasperação da pena em primeira fase, de modo que deve ser aplicada a regra do art. 33, § 3º, do Código Penal e igualmente fixado o regime inicial fechado. A corroborar o entendimento aqui adotado, destaco jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS EXASPERAÇÃO DA CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. AÇÕES PENAIAS EM ANDAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE DESPROVIDO. [...] ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO (....) IX - In casu, o regime adequado à hipótese é o inicial fechado, uma vez que houve fundamentação idônea a lastrear a aplicação do regime mais gravoso, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes, em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, parágrafo 2º, b, e parágrafo 3º, do Código Penal, e art.42 da Lei n. 11.343/06. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.587/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020) 4. Inexiste constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso, ante o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis (natureza e quantidade da droga), consoante orientação do art. 33, § 2º e 3º, do Código Penal. Nessa extensão, inalterada a reprimenda (7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado), fica prejudicado o pleito de substituição da pena

corporal por restritivas de direitos. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 577.166/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020)

(...) 6. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 7. In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante 6 anos e 6 meses de reclusão, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável. 8. Agravo regimental desprovido (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 671.879 - RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 23/11/2021, SEXTA TURMA).

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta.

Por estas razões, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Raphael Luiz Pereira à pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando que ostenta inúmeras anotações de registros infracionais, relativos ao período em que ainda menor de 18 anos de idade, o que indica que sua liberdade configura risco à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Expeça-se certidão de honorários à defensora dativa.

Custas ex lege, observada eventual gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 26 de janeiro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA